

1501325-18.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA CHEQUE DE FREITAS

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas. Atualmente ele se encontra preso pelo mesmo crime de tráfico de drogas.

Na fase policial, WILLIAN negou a prática do delito. Disse que descia a rua quando uma pessoa conhecida por "Neguinho" vinha correndo e esbarrou, derrubando drogas ao solo. Assustou-se, mas continuou andando. A polícia o abordou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

2ª Vara Criminal

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

1501325-18.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501325-18.2021.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA CHEQUE DE FREITAS

Vistos.

WILLIAN NATAN APARECIDO PINHEIRO e MARCOS MATHIAS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 06 de dezembro de 2021, por volta das 20 horas, na Rua Maracanã, n. 418, Jardim Imperial, nesta cidade e Comarca, previamente ajustados entre si e com unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de tráfico ou qualquer outra forma de disseminação, 51 porções de cocaína e 24 porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (p. 93/95).

Notificados (p. 130 e 132), ocasião em que receberam cópia da denúncia, os réus apresentaram defesa preliminar (p. 151/153). Recebida a denúncia (p. 160/161), o réu WILLIAN foi citado em juízo. O réu MARCOS, não localizado, teve a revelia decretada. Em audiências, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, interrogado o réu WILLIAN e realizados debates orais.

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, observo que, em que pese o acusado MARCOS MATHIAS não tenha sido formalmente citado, vez que em local incerto e não sabido, foi regularmente notificado (p. 130), ocasião em que recebeu cópia da denúncia. Assim, o réu foi

notificado a apresentar a defesa preliminar e foi patrocinado no transcorrer de toda causa por defensor dativo, sendo-lhe oportunizado o contraditório. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE CITAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RITO ESPECIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL REALIZADA. DEFESA PRÉVIA. RÉU REVEL. DEFESA TÉCNICA AO LONGO DE TODO O PROCESSO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL E PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. READEQUAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PROCESSO EM CURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. ... 3. Hipótese em que o paciente foi notificado regularmente para responder à acusação por escrito nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06. Todavia, a citação pessoal restou frustrada porque o agente evadiu-se do sistema prisional, o que ocasionou a decretação de sua revelia. Logo, não há se falar em cerceamento de defesa, pois o réu tinha ciência da acusação contra ele oferecida e permaneceu devidamente assistido durante todo o processo pela Defensoria Pública... (HC 616.133/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

No mérito, a acusação é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se perfeitamente demonstrada pelos autos de p. 15/18, pelas fotografias de p. 46/47, pelo laudo de p. 193/195, bem como pela prova oral colhida. A autoria é igualmente certa.

Os guardas civis disseram que efetuavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, oportunidade em que se depararam com os acusados em atitude suspeita, sendo que um deles permaneceu parado – depois reconhecido como MARCOS – e o outro, WILLIAN, tentou se evadir, caminhando no sentido oposto e dispensando um embrulho de papel embaixo de um ônibus. Procedida a abordagem, com MARCOS, em seu bolso, foram encontradas vinte e sete porções de cocaína, doze de crack e R\$ 46,00 dispostos em notas trocadas. De pronto, MARCOS assumiu informalmente a traficância. No embrulho dispensado por WILLIAN, verificou-se que havia vinte e quatro porções de cocaína, doze de crack e R\$ 140,00. Indagado, WILLIAN negou a traficância. (p. 03/06)

A testemunha Luis Henrique Leme acrescentou que toda droga estava embalava individualmente, pronta para a comercialização. Os acusados já eram conhecidos dos meios policiais. WILLIAN teve várias passagens pela Vara da Infância (p. 196/197).

Nesta audiência, a testemunha Erik corroborou o depoimento prestado na fase policial. Disse que o corréu WILLIAN já foi apreendido por ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas. Atualmente ele se encontra preso pelo mesmo crime de tráfico de drogas.

Na fase policial, WILLIAN negou a prática do delito. Disse que descia a rua quando uma pessoa conhecida por “Neguinho” vinha correndo e esbarrou, derrubando drogas ao solo. Assustou-se, mas continuou andando. A polícia o abordou posteriormente e o apontou como proprietário dos entorpecentes (p. 07).

Em Juízo, negou a conduta criminosa, afirmando que descia sentido Rua Maracanã, no mercadinho, para comprar ingredientes para o jantar. Viu dois indivíduos próximos e com a aproximação da viatura, um deles saiu caminhando e MARCOS permaneceu no local. Os guardas retiraram o réu do interior do mercadinho e mesmo MARCOS negando qualquer participação de WILLIAN no tráfico, acabou detido. Negou que levasse consigo porções de drogas ou dinheiro. Disse que a família mantém conta no mercadinho e que marcou o que adquiriu naquela data. Afirmou que nas outras ocasiões em que apreendido pelos mesmos guardas municipais, quando menor de idade, também nada de ilícito levava consigo.

Na fase policial, MARCOS confessou a conduta criminoso. Disse que “estava servindo um cliente na loja” – alusão ao tráfico de entorpecentes que realizava –, quando policiais o abordaram. Negou conhecer o corréu WILLIAN, afirmando que havia outro indivíduo, conhecido por Neguinho, que também estava vendendo drogas. Neguinho, que usava camisa azul e boné preto, correu ao notar a presença da guarda, tendo trombado com WILLIAN e dispensado a droga. Informou ter conhecimento de que os policiais já conheciam WILLIAN e que tentaram incriminá-lo. Negou conhecer Neguinho (p. 08)

O réu não foi mais encontrado e teve a revelia decretada.

Encerrada a instrução, as provas carreadas aos autos são suficientes para a prolação de um decreto condenatório.

Os guardas civis, de maneira firme e uníssona, narraram detalhadamente a dinâmica dos fatos, a visualização dos réus em atitude suspeita, a abordagem e apreensão de entorpecentes com MARCOS, bem como a tentativa de fuga de WILLIAN, o qual dispensou drogas embaixo de um ônibus.

Refutar a validade de um depoimento baseando-se apenas na qualidade ou na profissão do depoente, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos, denota nada mais que preconceito e generalização com base em casos isolados. Se alguém não é digno de fé, que não o seja por questões objetivas e, acima de tudo, conhecidas, e não apenas pelas funções que exerce.

O agente de segurança é recrutado mediante concurso público para atuar na prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício.

Além disso, nada nos autos indica que as testemunhas tenham se unido para, levianamente, incriminar pessoas inocentes..

Irrelevante para a configuração do crime ser o réu surpreendido no ato de comércio, na medida em que o artigo 33 da Lei 11.343/06 detalha todos os verbos que constituem o tipo penal, sendo certo que não há somente o verbo vender. Nesse sentido:

(...) para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes nem é necessária a prova flagrante do comércio ilícito, posto que suficientes os elementos indiciários apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da prisão para evidenciar tal atividade delitativa. Confira-se: 'Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminoso, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente' (RT 584/347) (trecho extraído do acórdão da Apelação nº 0003190-12.2009.8.26.0048, desta Comarca, julgado pela 14ª Câmara Criminal, tendo como relator Des. Fernando Torres Garcia, julgado em 17/02/11).

A corroborar o conjunto probatório há a confissão policial do corréu MARCOS, que se mostra elemento probatório inequivocamente apto a carrear a condenação, sobretudo porque confirmada pela prova oral. Nesse sentido:

As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais (STF RTJ 88/371);

Quanto ao envolvimento de WILLIAN no crime, a versão de MARCOS, na tentativa de afastar a responsabilidade de seu comparsa, não merece acolhida. Isso porque as testemunhas confirmaram haver presenciado o momento exato em que WILLIAN dispensou o embrulho com entorpecentes sob um ônibus. Além disso, em que pese tenha apontado a pessoa de Neguinho como o responsável pelos entorpecentes, MARCOS não soube informar sua qualificação, negando conhecê-lo, apesar de saber que vendia drogas no mesmo ponto de tráfico que o seu. Ora, é querer abusar da inteligência mediana supor que havia outro traficante no local – o qual nem sequer foi visto pelos guardas municipais e que todos sabiam ser traficante, mas ninguém sabia a qualificação – que dispensou as drogas no momento em que esbarrou com o acusado WILLIAN, induzindo as testemunhas em erro ao suporem que o entorpecente a ele pertencesse.

Não bastasse a forte prova oral colhida, a quantidade e variedade de entorpecentes, o valor apreendido e a dinâmica da diligência, analisados em conjunto, reforçam a certeza de que os réus traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, entorpecentes para entrega a terceiras pessoas, sendo de rigor o afastamento das teses defensivas de absolvição e desclassificação.

Por outro lado, não obstante a proximidade do local dos fatos a Escola Municipal Professor Waldemar Bastos Buhler, consoante laudo de p. 141/143, não há prova segura de que a conduta criminosa dos acusados se destinava de alguma forma a atingir os frequentadores do estabelecimento, sobretudo em razão do horário em que praticado o delito, escola municipal que funciona apenas durante o dia, não sendo suficiente para incidência da causa de aumento em tela apenas o fator espacial. Nesse sentido, ensina Renato Brasileiro de Lima:

As penas dos crimes dos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas também deverão ser aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), se a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais (v.g., penitenciárias, centros de detenção provisória), de ensino (v.g., faculdades, colégios) ou hospitalares (v.g., pronto-socorro, posto de saúde), de sedes de entidades estudantis (v.g., diretórios acadêmicos), sociais (v.g., associações de bairro), culturais (v.g., museus, centro de exposições), recreativas (v.g., clubes), esportivas (v.g., ginásios, estádios), ou beneficentes (v.g., orfanatos), de locais de trabalho coletivo (v.g., empresas), de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza (v.g., boates, cinemas, casas de espetáculos), de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social (v.g., clínicas de reabilitação), de unidades militares ou policiais (v.g., batalhões da Polícia Militar) ou em transportes públicos (v.g., ônibus, metrô). Como se percebe, a justificativa para a existência desta majorante diz respeito à enorme facilidade de disseminação do consumo de drogas nesses locais em virtude da maior concentração de pessoas, o que acaba por representar maior risco à saúde pública. Na medida em que não se admite o emprego de analogia in malam partem no Direito Penal, forçoso é concluir que se trata de rol de natureza taxativa. Por isso, se o local onde o crime de tráfico de drogas não constar do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 não será possível a incidência da referida majorante, ainda que se trate de local de grande aglomeração de pessoas (v.g., praça pública). (grifo nosso) (Legislação Criminal Especial Comentada: volume único. 8ª ed. rev., atual. e ampl. – Editora Juspodivm, 2020, p. 1.099/1.100).

Não é o caso de se reconhecer a agravante de calamidade pública. Ressalto que embora os fatos apurados tenham sido praticados pelos réus durante estado de calamidade pública, em vigência desde o dia 20 de março de 2020 após a publicação do Decreto Legislativo nº 6/2020, em razão da pandemia Covid-19, entendo que apenas o cometimento de crime durante tal período se mostra insuficiente para a caracterização da agravante prevista no artigo 61, II, j, do Código Penal, que exige circunstâncias concretas que comprovem a facilitação da ação pelo momento enfrentado. Assim, não tendo sido demonstrada a presença de qualquer facilidade

para a prática do delito decorrente da situação de calamidade, como, por exemplo, a diminuição ou nenhuma capacidade de estado policial, pelo contrário, os réus foram presos em flagrante delito, demonstrando a pronta atuação dos agentes de segurança, deixo de reconhecer a agravante.

Comprovadas, pois, autoria e materialidade delitivas, de rigor a condenação dos réus.

Passo a dosar as penas.

Assim, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade dos réus, às circunstâncias do crime e às demais diretrizes norteadoras do artigo 59 do Código Penal, em face do preceito sancionador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

A pena base foi fixada em patamar 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias e consequências do crime, já que os réus traziam consigo diversos entorpecentes, dentre eles o crack e seu alto poder vulnerante, indicando dolo e culpabilidade exacerbados e necessidade de maior reprimenda, justificando, pois, a fixação da pena no patamar indicado.

Na segunda fase, em razão da confissão policial do corréu MARCOS e da menoridade penal relativa de WILLIAN, atenuo a pena ao patamar mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na terceira fase, entendo não ser o caso da diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, considerando que os acusados não comprovaram atividade lícita que lhes possibilitassem a manutenção e sustento, tendo inclusive MARCOS informado aos policiais que estava traficando no momento da abordagem, indicando habitualidade e que dependa do tráfico para sua manutenção e sustento. Além disso, procurado e não localizado, ainda que em liberdade provisória, houve a informação de que se mudou para o Rio de Janeiro devido "a uns B.Os", tudo a indicar que se dedique a atividades criminosas. Da mesma maneira quanto a WILLIAN, tendo respondido a ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas quando menor de dezoito anos e atualmente, depois de beneficiado com a liberdade provisória nestes autos, encontra-se preso preventiva pelo mesmo delito, indicando, pois, que se dedica à atividade criminosa em tela. Nesse sentido:

SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELOS DELITOS DE TRÁFICODE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) E POSSE ILEGALDE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART, 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003) (...) Anoto que o acusado se dedicava à prática delituosa com frequência e habitualidade, não conseguindo comprovar qualquer atividade lícita, aliás, o próprio réu admitiu que não trabalhava, tampouco estudava, indicando com clareza, que fazia do tráfico o seu meio de vida. Reitere-se: a Lei de Drogas faculta (grifo nosso) ao magistrado sem obrigar a concessão do redutor, estando ele livre ainda para estabelecê-lo no patamar que entender adequado, diante da análise do caso concreto, respeitando-se o princípio da individualização da pena. E no caso não cabia a aplicação da benesse em razão das características do crime apurado, que se revelou típico de quem se dedica às atividades criminosas, deixando, assim, de preencher um dos requisitos do citado dispositivo. Ora, ainda que não se tenham provas exatas, inconcussas, sobre a organização criminosa à qual pertencia, evidente que para vender e negociar droga sem qualquer lugar, o acusado deveria necessariamente estar inserido na estrutura da criminalidade estabelecida naquela região, ressabido que não há, ainda, "livre concorrência" na venda de drogas. E não se trata aqui de suposição ou mera conjectura, pois é de conhecimento público a disputa de pontos de venda de drogas

entre as organizações criminosas rivais. Notório que a atividade da traficância assumiu características de negócio, sendo hoje fonte de renda do crime organizado, até porque os responsáveis pela estruturação da venda de drogas controlando as etapas de produção, transporte e acondicionamento não confiariam a entrega a consumidor final a uma pessoa que não gozasse da confiança deles, ou que não tivesse com eles algum vínculo (grifo nosso)(TJSP, Ap.0005783-67.2016.8.26.0048, desta 2ª Vara Criminal, 12ª Câ. Criminal Extraordinária, Relª., Desª., Ivana David, j. 10.05.2018);

TRÁFICO DE DROGAS - (...) Também não era mesmo o caso de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Sabe-se que o redutor não pode incidir como regra, bastando seja o agente primário e de bons antecedentes, mas, sim, excepcionalmente, ao traficante eventual, como por exemplo: viciado que fornece parte de sua droga para outro usuário, porque em falta o entorpecente nos pontos de venda ilícita. E essa não é a situação dos autos. O réu estava transportando enorme quantidade de crack, de um estado para outro, e não comprovação ocupação lícita, ficando evidente que fazia do tráfico seu meio de vida. Não é demais lembrar, ainda, que o legislador previu a redução para os delitos previstos no art. 33, caput, e § 1º, da Lei n. 11.343/06, e não quando combinados com o art. 40, do mesmo diploma legal. Aliás, nem teria razão a previsão legal, ao mesmo tempo, de um aumento e de uma redução. Nesse sentido, a doutrina de Renato Marcão: "A causa de redução prevista no § 4º alcança apenas os crimes previstos no caput e § 1º do art. 33 da Lei 11.343/2006." (Tóxicos, 7ª edição, São Paulo: Ed. Saraiva, p. 164) (TJSP, Ap. 0000360-56.2017.8.26.0545, desta 2ª Vara Criminal, 7ª Câ. Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Simão, j. 25/10/2017).

Inexistindo qualquer outra circunstância modificadora aplicável, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente acusação movida em face de WILLIAN NATAN APARECIDO PINHEIRO e MARCOS MATHIAS SANTOS, já qualificado nestes autos, para, com fundamento no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, CONDENA-LOS a cumprir, no regime inicial fechado, a pena de 05 (cinco) anos reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Considerando o quantum da pena aplicada, a gravidade do crime praticado pelos réus, equiparado a hediondo, bem como o quanto considerado na fixação da pena base e na terceira fase de aplicação da pena, incabível regime diverso do fechado para início de cumprimento da pena, bem como substituição por restritiva de direitos.

O fato de ser considerado crime cometido sem violência ou grave ameaça não afasta a hediondez do delito e sua extrema gravidade, não havendo regime diverso que o fechado que atenda ao binômio reprovação-prevenção previsto no artigo 59 do Código Penal. Assim, fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena e deixo de substituir a pena por restritiva de direitos, sobretudo dada a quantidade de pena aplicada.

Pelas mesmas razões e por ter sido preso por crime semelhante quando em liberdade provisória pelo delito apurado nestes autos, decreto a prisão preventiva de WILLIAN, na medida em que necessária para a garantia da ordem pública, não podendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado. Expeça-se mandado de prisão, encaminhando-se ao estabelecimento penal onde se encontra detido.

Oportunamente, expeçam-se as guias competentes.

Com o trânsito em julgado:

1. Proceda-se ao cálculo de multa, dando-se ciência às partes. Decorridos cinco

dias sem manifestação, fica homologado o cálculo, caso em que deverá ser intimado o condenado para pagamento no prazo legal. Fica, desde já, deferido o fracionamento da multa em três parcelas mensais, iguais e consecutivas. Em caso de atraso em qualquer das parcelas, será imediatamente oficiado para inscrição na dívida, independentemente de nova intimação, descontados os valores já quitados;

2. Sem custas, vez que beneficiário da assistência judiciária (p. 137).
Ao defensor nomeado pelo Convênio OAB/DP, fixo os honorários no patamar dos atos praticados. Expeça-se certidão

3. Oficie-se ao Colendo Tribunal Regional Eleitoral da circunscrição de residência dos condenados, bem como ao IIRGD, com informações desta condenação, para os fins legais.

4. Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento do valor apreendido em poder dos réus. Oficie-se.

Incineração da droga já determinada na p. 56.

Publique-se e intímem-se.

Atibaia, 23 de maio de 2022.

CAROLINA CHEQUE DE FREITAS
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA